

既判力の物的範圍에 관한 小考

- 訴訟物理論을 중심으로 -

충북대학교 법과대학 부교수·변호사 金 建 昊

논문요약

기관력은 소송물에 대해 행한 일정시점의 판단으로써 일정한 사항에 대하여 일정한 사람을 구속하게 되는데, 기관력이 어떠한 사항에 관하여 미치는가 하는 것이 기관력의 물적 범위 문제이다. 이에 관하여 우리 민사소송법은 기관력은 상계항변의 경우를 제외하고 판결주문에 포함된 판단에만 생기는 것이 원칙임을 밝히고 있다. 그런데 판결주문에는 본안판결의 경우 소송물의 존재 또는 부존재에 관한 판단이 표시되므로 결국 기관력은 소송물의 존부에 관한 판단에 한하여 발생하게 된다는 것이 된다. 종래 우리나라의 판례와 일부 학자들은 구소송물이론에 입각하여 소송물의 개념을 실체법적으로 파악함으로써 기관력의 인정 범위가 지나치게 협소해 지게 되었다. 그 결과 법적 안정성과 분쟁의 1회적 해결은 물론 소송경제 역시 도모할 수 없게 된다는 비판을 받아왔다. 이에 반해 소송물의 개념 내지 단복·이동을 소송법적 요소에 의해 파악하여야 한다는 신소송물이론에 의하면 소송물의 크기가 확대된다. 그 결과 기관력의 범위 역시 확장됨으로써 법적 안정성 및 분쟁의 1회적 해결을 통한 소송경제를 도모할 수 있게 된다는 장점이 있다. 다만, 신소송물이론을 따를 경우 필연적으로 확장되는 기관력에 의하여 당사자의 신소 제기권 또는 권리구제의 기회가 부당하게 박탈되지 않도록 당사자는 가능한 모든 공격방어방법을 변론에서 주장할 것이 필요하고 법원 역시 석명권 내지 지적의무를 적극적으로 행사하여야 할 것이다.

[주제어] 기관력의 물적 범위, 본안판결, 소송판결, 소송물, 구소송물이론, 신소송물이론
objektive Grenzen der Rechtskraft, Sachurteil, Prozeßurteil, Streitgegenstand, ursprüngliche materiellrechtliche Theorie, prozessrechtliche Theorie

* 논문접수 : 2007. 5. 30. * 심사개시 : 2007. 6. 5. * 게재확정 : 2007. 8. 24.

目 次

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| I. 총 설 | III. 판결이유 중의 판단 |
| II. 원칙 - 판결주문에 포함된 판단 | 1. 원 칙 |
| 1. 의 의 | 2. 문제점과 해결방법론 |
| 2. 판결주문 해석의 필요성 | 3. 예의(상계의 항변) |
| 3. 기관력의 범위와 소송물 | IV. 결 론 |
| 4. 판례의 태도 및 이에 대한 검토 | |

I. 총 설

(1) 민사판결은 법원이 사인간의 법률관계에 관한 분쟁을 확정함으로써 사건을 보호함과 아울러 사법질서를 유지하려는 목적으로 제반 법규정 절차에 따라 행한 공권적 판단이라 할 수 있는데, 원고의 소 제기 행위에 의하여 법원에 계속 중이던 민사소송에 관하여 중국판결이 선고되어 당사자가 상소와 같은 통상의 불복신청방법에 의해서 더 이상 그 판결의 취소를 구할 수 없게 된 경우 판결이 형식적으로 확정되었다고 하고 이러한 당사자에 의한 판결의 취소불가능성을 판결의 효력 중 하나로 파악하여 형식적 확정력이라 한다. 중국판결이 형식적으로 확정되면 그 판결에 표시된 청구에 관한 판단내용은 당사자간의 법률관계 및 법원을 규율하는 새로운 기준으로서 구속력을 갖게 되어 동일사건이 재차 문제될 때에 당사자는 앞의 판결에서의 판단내용에 모순되는 주장을 하면서 이를 또 다시 되풀이 하여 다투는 것이 허용되지 않고 법원도 앞의 판결에서 행한 판단과 모순, 저촉되는 판단을 할 수 없게 되는데 이와 같이 형식적으로 확정된 중국판결의 판단내용에 부여되는 규준성 내지 통용력을 기관력 또는 실체(질)적

확정력이라 한다.¹⁾

따라서 기판력은 당사자에 대하여는 전소판결의 내용과 모순되는 주장을 할 수 없다고 하는 행위규범(Verhaltensnorm)이 되고 법원에 대하여는 전소판결의 내용과 저촉되는 판단을 하여서는 아니된다는 재판규범(Entscheidungsnorm)이 되는 것이다.

(2) 기판력을 정당화하는 이유 내지 그 인정 근거²⁾에 대한 전통적 견해는 법적 안정설이다. 즉 판결의 형식적 확정력만으로는 동일한 소송물에 관하여 제2의 소송절차에서 또 다시 다투어지는 것을 방지할 수 없을 뿐만 아니라 또 다시 소송이 되풀이되는 경우 전소에서의 판결과 서로 모순·저촉되는 판결이 나오는 것을 피할 수 없게 되는데 기판력을 인정함으로써 이를 모두 방지할 수 있고 그 결과 법적 안정성과 법적 평화를 확보할 수 있게 된다는 것이다.³⁾

(3) 기판력은 소송상 청구(소송물)에 대해 행한 일정시점의 판단으

1) 대판 1987. 6. 9. 86다카2756 사건에서 “확정판결의 기판력이라 함은 확정판결의 주문에 포함된 법률적 판단의 내용은 이후 그 소송당사자의 관계를 규율하는 새로운 기준이 되는 것이므로 동일한 사항이 소송상 문제가 되었을 때 당사자는 이에 저촉되는 주장을 할 수 없고 법원도 이에 저촉되는 판단을 할 수 없는 기속력을 의미하는 것”이라고 하고 있다.

2) 이에 관하여는 법적 안정설 이외에도 당사자가 전소에서 사실을 주장하고 증거를 제출하는 등 자신이 소송상 청구를 이유있게 하기 위하여 공격방어방법을 제출할 기회를 대등하게 부여받은 이상 즉 구체적인 절차적 보장을 받은 이상 법원이 행한 판단을 수용하여야 할 자기책임을 부담하게 되는 것이라고 보는 절차보장설과, 법적 안정성과 아울러 절차보장의 요구의 충족에 의한 당사자의 자기책임에 있다고 보는 이원설, 그리고 절차보장, 법적 안정성, 재판제도로서의 모순판단의 회피, 소송경제 등 다원적으로 그 근거를 파악해야 한다는 다원설 등이 대립되어 있다. 자세한 것은 국순옥, “기판력의 본질과 작용”, 민사법연구 제11집 제1호 참조.

3) 新堂幸司, 民事訴訟法, 筑摩書房, 1991, 428면.

로써(시적 범위) 일정한 사항에 대하여(물적 범위) 일정한 사람을(주관적 범위) 구속하게 되는데,⁴⁾ 이와 같이 세 가지 관점에서 파악되는 기판력의 범위 중 기판력이 어떠한 사항에 관하여 미치는가 하는 것이 바로 기판력의 물적 범위 내지 객관적 범위의 문제이다. 이에 관하여 우리 민사소송법(이하 “법”이라 한다) 제216조 제1항은 “확정판결은 주문에 포함된 것에 한하여 기판력을 가진다”라고 규정함과 아울러 같은 조 제2항은 “상계를 주장한 청구가 성립되는지 아닌지의 판단은 상계하자고 대항한 액수에 한하여 기판력을 가진다”라고 규정하여 기판력은 상계항변의 경우를 제외하고 판결주문에 포함된 판단에만 생기는 것이 원칙임을 밝히고 있으나 이에 관하여는 현재 몇 가지가 문제 되고 있다.

우선 첫 번째로 기판력이 발생하는 대상인 “확정판결의 주문에 포함된 것”의 해석과 관련해서 기판력의 물적 범위가 곧 소송물이라는 원칙(기판력의 물적 범위 = 소송물)에 의하면 소송물의 범위를 어떻게 확정할 것인가가 문제가 되고 그 결과 소송물에 관한 논쟁은 기판력 분야에도 그대로 연결되어 문제가 되고 있고, 두 번째로 금전채권과 같이 수량적으로 가분할 수 있는 가분채권에 있어서 원고가 가분채권의 일부를 임의로 분할하여 청구한 경우에 그 일부청구에 대하여 내린 판결의 기판력이 잔부청구에 대하여도 미치는가가 문제되고 있으며, 세 번째로 기판력이 판결주문에 포함된 것에 한하여 발생하므로 판결이유 중의 판단에는 상계의 항변을 제외하고는 기판력이 발생하지 않는다고 보아야 하는데 이 원칙을 예외 없이 그대로 관철할 경우 판결의 필수적인 전제가 되었던 선결적 법률관계에 관하여 조차 기판력이 인정되지 않음으로써 훗날 그와 모순, 저촉되는 판결이 선고되어 법원에 대한 불신을 야기시킬 수 있게 된다는 문제가 바로 그것

4) 이시윤, 신민사소송법, 박영사, 2004, 527면.

이다.

(4) 아래에서는 위와 같은 몇 가지 문제점에 관하여 현재까지 논의되고 있는 학설을 검토하여 봄과 아울러 이에 관한 우리 법원의 입장을 판례를 통해 정리해 보고자 한다.

II. 원칙 - 판결주문에 포함된 판단

1. 의의

기판력의 물적 범위는 기판력이 확정판결에서 표시되고 판단된 사항 가운데 어떠한 사항에 관하여 미치는가의 문제이다.⁵⁾ 기판력은 앞서 본 바와 같이 판결주문에 포함된 사항에 한하여만 발생하게 됨이 원칙이므로(법 제216조 제1항) 판결이유에서는 판단되었으나 판결주문에 나타나지 않은 사항은 기판력이 발생하지 않게 되고, 반대로 판결이유 중에 판단되지 않은 사항이라 하더라도 판결주문에서 판단된 사항에는 기판력이 발생하게 된다.⁶⁾ 그런데 판결주문은 소장의 청구 취지에 대응하는 것으로써 본안판결의 경우 원고의 소송상 청구의 존

5) 갑이 X라는 물건의 소유권자임을 전제로 이를 점유하는 을을 상대로 소유권에 기한 인도청구소송을 제기하고 이에 대한 승소판결이 확정된 경우 그 판결주문에는 “을은 갑에게 X를 인도하라”라고 표시됨으로써 “갑의 을에 대한 인도청구권이 존재한다”라는 판단을 받게 되는데 이 경우 판결이유에서는 갑이 X라는 물건의 소유권자인지의 여부에 관한(즉 선결적 법률관계에 관한) 판단이 표시되게 된다. 또한 만약 위 인도청구소송에서 피고에 의해 유치권 항변이나 동시이행의 항변이 제출되었을 경우 그 판결이유에서는 유치권의 피담보채권이나 동시이행을 주장한 반대채권의 존부에 관한 판단이 표시되게 된다. 이와 같이 확정판결에 나타난 여러 가지 판단사항 가운데 어떠한 사항에 관하여 기판력이 생기는 것인가의 문제가 바로 기판력의 물적 범위인 것이다.

6) 김용진, 민사소송법, 신영사, 2003, 609면.

재 또는 부존재에 관한 판단이 표시되는 것이므로 이는 결국 기판력이 소송물의 존부에 관한 판단에 한하여 발생하게 된다는 것이 된다. 여기서 기판력의 물적 범위 = 주문 = 소송물이라는 원칙 내지 전통적 명제가 성립되게 된다.⁷⁾

이와 같이 기판력이 판결주문에 포함된 것에 관해서만 발생하고 판결이유 중의 판단에 발생하지 않는 것은 1) 판결의 주문은 재판의 결론으로써 당사자의 소송목적이자 당사자 간의 주된 관심사인 소송상 청구를 판단한 것이므로 이에 대해 기판력을 인정하는 것이 당사자의 의사에 부합되고, 2) 당사자는 소송상 청구에 관하여 공격, 방어를 다하는 것이 기대되므로 이에 기판력을 인정하는 것은 절차권 보장 및 예상외의 재판방지에 적합하며,⁸⁾ 3) 소송상 청구가 소송의 목적이거나 판결이유 중에 판단된 당사자의 주장은 이를 달성하기 위한 수단 이 되는 것이라 할 수 있으므로 당사자가 목적달성을 위하여 신중을 기하지 않고서 여러 쟁점에 대해 주장을 할 가능성이 항존함에도 불구하고 그에 대한 판단에 기판력을 생기게 하여 다른 소송물과의 관계에서 그것을 다투지 못하게 하는 것은 당사자에 대한 예상외의 타격이 될 염려가 있고, 4) 또한 판결이유 중의 판단에도 기판력이 생기게 되면 법원은 실체법상의 논리적 순서에 따라서 공격방어방법 전부를 신중하게 순서에 따라 판단하지 않으면 안 되게 되어 심리의 탄력성을 잃게 되고 절차가 지나치게 복잡하게 되기 때문이다.

2. 판결주문 해석의 필요성

7) 다만, 소송판결의 경우에는 판결이유에서 판단되는 소송요건의 흠결에 관한 판단에 기판력이 생긴다는 것이 통설 및 판례의 태도인데 이에 관해서는 후술한다.

8) 이시윤, 앞의 책, 534면; 정동운·유병현, 민사소송법, 법문사, 2006, 702면

기판력이 판결주문에 포함된 사항에 한하여 발생한다고는 하지만 실제로 판결주문은 일반적으로 무색무취하고 대단히 간결하게 표현된다. 즉 실무상 소송판결의 경우에는 “이 사건 소를 각하한다”라고, 청구기각판결의 경우에는 “원고의 청구를 기각한다”라고 표시될 뿐이고 이행의 소에 있어서의 청구인용판결도 “피고는 원고에게 돈 1,000만 원을 지급하라”라는 식으로 간결하게 표시될 뿐이기 때문에 기판력이 생기는 구체적 사항을 파악하기 위해서는 판결이유를 참조하여 주문을 명확하게 해석해야 할 필요가 있는 것이다.⁹⁾ 그러나 그렇게 하더라도 판결이유에는 청구취지를 비롯하여 청구원인을 구성하는 사실관계 및 법률적 판단 등을 참조하거나 고려하여야 할 여러 요소들이 많이 있기 때문에 구체적으로 기판력이 발생하는 사항을 명확히 특정하는 것은 현실적으로 대단히 어려운 일이고 그 당연한 귀결로써 당사자가 후소에서 행하는 어떠한 권리주장까지가 기판력에 의해서 배척되는가를 판단하는 것 역시 대단히 어려운 문제가 된다.¹⁰⁾

3. 기판력의 범위와 소송물

가. 서론

기판력의 물적 범위가 곧 소송물이라고 보는 전통적 명제에 의하면 소송물의 크기(동일성)가 어떻게 결정되는가(소송물이론)에 따라 기판력의 물적 범위는 자동적으로 결정되므로 전자가 크면 후자도 당연히 커지고 전자를 확대하지 않고는 후자도 넓어 질 수 없으며, 소송물의 개념에 포함되지 않는 것 예컨대 사실, 선결적 법률관계, 항변(다만

상계의 항변은 제외), 법규의 해석적용 등에 관하여는 기판력이 발생하지 않는다는 결론이 된다. 따라서 무엇을 기준으로 소송물을 확정할 것인가 즉 소송물을 파악하는 관점에 따라 소송물의 단복·이동(單複·異同)이 결정될과 아울러 기판력의 존부도 동시에 결정되게 되는 것이다.¹¹⁾ 종래 우리나라 판례와 과거 일부 학자들은 소송물을 실체법적으로 파악하여 소송물을 권리 또는 법률관계의 주장으로 보는 이른바 구소송물이론을 따르면서 동일한 권리를 법률적 관점만을 바꾸어 제소하여도 소송물이 다르다 하여 기판력이 미치지 않게 함으로써 관련분쟁을 실질적으로 한꺼번에 해결하지 못하는 등의 여러 가지 문제점이 있다는 비판을 받아왔는데 근래에 이르러는 위와 같은 구소송물이론의 문제점을 비판하면서 등장한 신소송물이론이 국내외 다수의 학자들로부터 지지를 받으면서 주류적 견해가 되어있고,¹²⁾ 나아가 “소송물이 곧 기판력의 물적 범위이다”라는 전통적 명제에서 벗어나 소송물개념의 통일적 구성을 포기하고 소송절차를 지배하는 원리 또는 소송절차의 국면에 따라 소송물의 개념을 상이하게 구성하거나 파악하지는 시도도 나오고 있다.¹³⁾ 본 글의 주된 목적은 기판력의 물적 범위를 소송물이론을 빌어 효율적으로 확정하여 보자는 것에 있으므로 그에 필요한 한도 내에서 소송물이론을 간략하게 살펴봄과 아울러 이에 따른 기판력의 범위를 검토해 보기로 한다.

11) 柏木邦良 “訴訟物概念の機能”, 民事訴訟法の争点(ジュリスト신판), 1988, 7, 178면; 이것을 訴訟物 概念의 優越性이라고도 한다.

12) 이시윤, 앞의 책, 205면; 정동윤·유병현, 앞의 책, 237면; 오시영, 앞의 책, 328면; 김용진, 앞의 책, 147면; 김홍규, 앞의 책, 200면 이하; 강현중, 민사소송법, 박영사, 2002, 329면.

13) 통일적인 소송물개념의 정립을 포기하고 다양하게 구성하려는 입장이 그것인데 이를 상대적 소송물이론이라 한다. 자세한 것은 이시윤, 앞의 책, 207면; 정동윤·유병현, 앞의 책, 239면; 전병서, 민사소송법강의, 법문사, 2003, 252면; 김용진, 앞의 책, 147면.

9) 秋山幹男 외 5人, コメントール 民事訴訟法II, 日本評論社, 457면.

10) 그 주장은 소송상 청구 또는 소송물 그 자체로 나타나기도 하고 선결문제로 나타나기도 한다. 정동윤·유병현, 앞의 책, 703면.

나. 소송물의 개념 및 소송법상 기능

민사소송에 있어서 소송의 주체를 당사자라고 하는 반면 소송의 객체를 소송물, 소송상 청구 또는 심판의 대상이라고 한다. 우리 법상 소송물을 나타내기 위하여 소송물(민사집행법 제48조 제2항), 소송목적(법 제26조, 제67조, 제83조, 민사소송인지법 제2조), 소송목적의 권리(법 제65조, 제81조, 제82조)라는 용어도 사용되나 일반적으로 청구(법 제220조, 제249조, 제253조, 제262조, 제263조 등)라는 용어가 사용되고 있다. 그러나 여기서의 청구는 실체법상의 청구와는 다른 개념이므로 강학상 이를 소송상 청구라 하고 있다. 소송물은 소송의 객체이므로 소송에서 다루어지고 있는 권리내용의 목적물인 제재물과는 구별하여야 한다. 예컨대 가옥명도청구소송에 있어서 명도청구권 내지 명도청구를 할 수 있는 법적인 지위가 있느냐의 여부가 심판의 대상으로서 소송물을 구성하는 것이지 그 목적물인 가옥은 소송물이 아닌 것이다. 이와 같이 소송물은 소송의 객체로서 소송절차의 모든 국면에서 중요한 기능을 수행하고 있는데 첫째, 소송절차의 개시와 관련하여 관할의 결정 및 심판의 대상과 범위를 특정하는데 기준이 되고 둘째, 소송절차의 진행과정에서 청구의 병합, 청구의 변경, 중복소송 등을 판단하는 기준이 되며, 셋째, 소송절차의 종결과 관련하여 소취하 후의 재소금지, 판결주문의 작성, 기판력의 물적 범위 등을 정할 때 기준이 된다. 또한 소제기에 따른 시효중단의 범위, 제척기간 준수의 범위 등 실체법상의 효과를 따질 때에도 소송물이 기준이 된다.¹⁴⁾

14) 이시윤, 앞의 책, 202면; 정동윤·유병현, 앞의 책, 226면; 오시영, 앞의 책, 314면.

다. 청구의 취지와 청구원인

(1) 소의 제기는 소장이라는 서면을 법원에 제출함으로써 행하여지는데(법 제248조, 소장제출주의)¹⁵⁾ 소장에는 당사자, 법정대리인, 청구의 취지와 원인을 기재하여야 한다(법 제249조). 이와 같이 청구의 취지와 원인을 소장의 필요적 기재사항으로 한 이유는 처분권주의가 적용되는 우리 민사소송에서는 원고가 소를 제기하려면 심판의 대상(소송물)을 명확히 특정하고 법원에 의한 분쟁해결의 범위를 명확하게 한정하여야 하는데 이들은 청구의 취지와 원인에 의해 명백해지기 때문이다.

(2) 청구의 취지는 원고가 소로써 바라는 권리보호의 형식과 법률효과를 기재하는 소의 결론부분이라 할 수 있다. 즉 원고가 어떠한 내용과 종류의 판결을 구하는지를 표시한 부분으로써 여기에는 심판의 대상과 분쟁해결방식을 간결하고 명확하게 표시하여야 한다.¹⁶⁾ 청구취지를 명확히 특정하지 않을 경우 관할의 결정, 소가산정 등이 곤란하고 법원도 청구취지에 따른 법률효과를 당사자에게 부여해 줄 수 없을 뿐만 아니라 기판력의 물적 범위도 불명확해 지고 강제집행의 대상도 불명확하게 된다. 소장의 청구취지란에는 그 밖에 소송비용의 부담과 가집행선고의 신청을 기재하는 것이 실무상 관행으로 되어있다.

(3) 법 제249조 소정의 청구의 원인이란 법률관계에 변동을 일으키는 법률요건사실(광의의 청구원인) 중에서 소송상 청구를 특정함에 필요한 한도의 사실관계 즉 소송상 청구를 다른 것과 구별시키고 오

15) 다만, 소액사건의 경우에는 간이하고도 신속한 분쟁처리를 위해 구술로써 제소할 수 있으나(소액사건심판법 제4조1항) 이 경우에도 구술로써 청구취지와 청구원인을 명백히 하여야 한다.

16) 원고가 이행, 확인, 형성의 소 중에서 어느 것을 바라고 그 내용은 무엇인지를 구체적으로 특정하여야 한다.

인, 혼동을 일으키게 하지 않을 정도의 사실을 말한다. 원고가 소장의 청구원인에 어느 정도까지의 사실을 기재하여야 하는가에 관해 종래 식별설과 이유기재설이 대립되어 있으나¹⁷⁾ 현재는 소송물에 관한 신·구이론에 관계없이 식별설이 통설로 되어 있다. 그러나 실무상으로는 소장의 청구원인 란에 소송물의 동일인식을 갖게 하는 사실 이외에도 여러 가지 주장이나 증거 등의 공격방어방법(광의의 청구원인사실)까지 함께 기재하는 것이 보통이므로 이를 구별할 실익은 적다고 본다.

라. 소송물이론과 청구의 취지 및 원인과의 관계

청구의 취지 및 청구의 원인은 소송물을 특정함에 있어서 그 식별 기준이 된다. 법률관계의 존부확인을 목적으로 하는 확인의 소에 있어서는 법률관계의 존부 자체가 심판의 대상(소송물)이 되기 때문에 청구의 취지의 기재 그 자체만으로 소송물이 특정된다고 보는 것이 일반적이다. 그러나 그 이외의 이행의 소나 형성의 소에 있어서도 그와 같이 볼 수 있는지는 문제이다. 왜냐하면 이행의 소나 형성의 소에 있어서는 경우에 따라서 하나의 법률요건에서 수개의 법률효과가 발생하는 경우도 있고 수개의 법률요건에서 하나의 법률효과가 발생하기도 하기 때문에 청구의 취지만으로 과연 소송물을 특정할 수 있는가가 논란이 되고 있는 것이다. 그리하여 원칙적으로 청구취지만으로 소송물이 특정되는가 아니면 청구원인의 기재사실도 고려되어야 하는가의 문제와 청구의 원인을 이루는 여러 사실관계를 원칙적으로

17) 식별설은 소송상 청구(소송물)의 동일성을 인식하는데 필요한 사실 즉 소송물을 다른 권리관계와 구별하는데 필요한 사실을 기재하면 족하다는 입장이고 이유기재설은 소송상 청구를 정당화시키는 모든 사실 즉 이를 이유 있게 하기 위한 모든 사실을 기재하여야 한다는 입장이다. 이시윤, 앞의 책, 229면; 정동윤·유병현, 앞의 책, 75면.

하나로 볼 것인가 아니면 각 별개인 여러 개로 볼 것인가 하는 문제를 둘러싸고 소송물이론이 대립되어 있는데 바로 여기서 청구의 취지와 청구의 원인 (또는 그것을 이루는 사실관계)이 중요한 의미를 갖게 되는 것이다.

마. 소송물이론과 기판력의 범위

소송물의 본질에 관한 논쟁은 1925년 독일의 Rosenberg 교수가 “민사소송에 있어서의 법률적 관점의 변경”¹⁸⁾에서 처음 문제 삼은 이래 최근에 이르기까지 민사소송법 분야에 있어서 가장 핵심적인 문제가 되고 있는데 소송물이론은 크게 소송물을 실체법적인 측면에서 파악하여 실체법상의 청구권으로 보거나 실체법상의 권리 또는 법률관계에 관한 주장으로 보는 입장(구소송물이론, 실체법설)과 이를 소송법적인 측면에서 파악하여 청구의 취지에 표시된 소송목적(법률효과의 주장)만으로 또는 이와 함께 청구의 원인인 사실관계로써 식별되거나 구성된다는 입장(신소송물이론, 소송법설) 및 실체법에 그 기초를 두면서 신소송물이론과 동일한 결론에 이르는 입장(신실체법설)으로 나눌 수 있다.

(1) 구소송물이론과 기판력의 범위

1) 소송물을 원고가 소송에서 행하는 실체법상의 권리 또는 법률관계에 관한 주장으로 보는 견해이다. 이에 따르면 “실체법상의 권리의 주장 = 소송물”이 되므로 원고가 주장하는 실체법상의 권리의 단복·이동(單複·異同)에 따라 소송물의 단복·이동이 결정된다.¹⁹⁾ 이행의

18) Rosenberg, Die Veränderung des rechtlichen Gesichtspunkts im Zivilprozeß ZZP, 49, 38ff.

19) 따라서 동일한 급부 또는 동일한 법률관계의 형성을 목적으로 하는 실체법상 권리(청구권 내지 형성권)가 경합된 경우, 원고가 계속 중인 소송절

소에서는 개개의 이행청구권, 확인의 소에서는 권리 또는 법률관계, 형성의 소에서는 개개의 형성권(형성원인 또는 형성요건)이 소송물의 내용을 이루는 것으로 본다. 또한 소장의 기재사항 중 청구의 원인에 기재된 사실(특히 권리의 발생원인사실)은 소송물인 권리 또는 권리 관계를 특정하는데 필요한 사실로 보아(다만 확인의 소의 경우는 청구취지만으로 특정된다고 한다) 이에 의하여 소송물의 단복·이동이 결정되는 것으로 봄으로써 소송물의 특정 내지 식별기준을 청구의 원인에서 찾는다.

2) 구소송물이론에 의하면 원고가 주장하는 실체법상의 권리나 법률관계가 바로 소송물이 되므로 기판력의 물적 범위도 그러한 실체법상의 권리나 법률관계에 한정되게 된다. 즉 법원에 의해 심판되어 확정된 개개의 실체법상의 권리 또는 법률관계에 관하여만 기판력이 미치게 되는 것이다. 따라서 판결이 확정된 후 전소와 동일한 실체법상의 권리에 기하여 후소를 제기하면 이는 기판력에 저촉되게 되나 전소에서 확정되지 않은 다른 실체법상의 권리에 기하여 후소를 제기하는 경우에는 비록 후소에서의 권리가 전소에서의 권리와 실체법상 경합관계에 있다 하더라도 기판력에 저촉되지 않게 된다. 또한 소송물의 동일성은 청구의 원인에 기재된 사실에 의하여 식별하게 되므로 청구의 원인에 기재된 사실이 다르면 청구의 취지가 동일하거나 청구의 기초가 공통된다 하더라도 기판력은 미치지 않는다. 따라서 동일

차에서 여러 개의 실체법상의 권리를 주장하면 청구의 병합이 되고, 종전에 주장하던 실체법상의 권리와 다른 실체법상의 권리로 바꾸어 주장하면 소(청구)의 변경이 되며, 소송계속 중에 다른 실체법상의 권리에 기하여 신소를 제기하여도 소송물이 다르므로 중복제소에 해당하지 않게 되고 따라서 판결이 확정된 후 전소와 다른 실체법상의 권리에 기하여 다시 후소를 제기하여도 기판력에 저촉되지 않게 되며 또한 원고가 주장하지 않은 다른 실체법상의 권리에 기하여 심판을 하게 되면 처분권주의에 위배되는 것으로 된다.

한 사실관계에 기하여 불법행위에 기한 청구권과 부당이득에 기한 청구권이 경합될 경우 원고가 그 중 하나의 청구권에 기해 제소하고 그에 대한 법원의 판단이 내려져 기판력이 발생했다 하더라도 다른 청구권에 기한 후소의 경우 전소와는 그 청구의 원인을 달리하기 때문에(즉 별개의 소송물이기 때문에) 기판력이 미치지 않게 된다는 것이다.²⁰⁾ 다만 청구권이 경합된 경우가 아니고 법조경합인 경우는 현실적으로 특별규정에 기초하여 한 개의 청구권 밖에 성립되지 않으므로 소송물은 하나일 뿐이라고 하고 있다.²¹⁾

3) 구소송물이론이 이와 같이 기판력의 물적 범위를 확정하는 것은 처분권주의를 배경으로 하고 있는 것으로 보인다. 즉 심판의 대상과 범위(소송물)를 어떻게 특정할 것인가는 원고의 의사에 일임되어 있는데 법원이 청구된 하나의 청구권에 관해서만 심판하고 다른 청구권에 관해서는 아무런 심판을 하지 않지 않았음에도 판결이 확정된 후 두 개의 청구권 모두에 관하여 기판력이 생긴다고 한다면 심판을 받지 않은 다른 청구권에 기해서는 다시 제소할 수 없다는 결론이 되는데 이는 원고 또는 권리자에게 참을 수 없는 피해를 주는 것이 되어 부당한 것이다.²²⁾ 그러나 소송물을 실체법상의 권리나 법률관계에 관한 주장으로 파악하는 동시에 그 동일성의 식별기준을 청구의 원인에 기재된 권리의 발생원인사실에 두는 구소송물이론은 동일한 하나의 사실관계에 기하여 청구권 또는 형성권(형성원인)이 경합될 경우 이를 별개의 소송물인 것으로 취급하고 기판력 역시 당해 청구권 또는 형성권에 대해서만 발생하고 법원이 심판하지 않은 잔여 청구권 또는

20) 兼子一, 民事訴訟法體系, 酒井書店, 1982, 167면. 동일물에 대하여 점유회수의 소를 제기하여 패소한 뒤에 소유권에 기한 반환청구를 하는 것도 허용된다고 한다.

21) 兼子一, 앞의 책, 166면.

22) 방순원, 민사소송법(상), 한국사법행정학회, 1987, 289면.

형성권에 대해서는 차단된다고 볼 수밖에 없게 되어 기판력이 미치는 범위가 지나치게 좁아지게 되어 동일분쟁에 관한 재판을 여러 차례에 걸쳐 반복하게 하는 등 분쟁의 1회적 해결요건에 반하게 된다. 그 결과 피고는 여러 차례에 걸쳐 응소를 강제당해야 하는 피해를 입게 되고 법원 역시 여러 차례에 걸쳐 재판권을 발동하여야 함에 따른 국가적, 사회적 손실이 막대하게 된다. 또한 원고는 한 소송에서 모든 소송자료를 제출해 놓고 총력전을 펴야 한다는 집중심리주의 방식에 의한 소송운영에 지장을 초래하게 되는 등 여러 가지의 문제점이 있다.²³⁾ 이와 같은 이유로 현재 구소송물이론은 신소송물이론에 밀려 일본과 우리나라의 소수설로 전락해 있다.

(2) 신소송물이론과 기판력의 범위

1) 소송물을 실체법상의 권리에 의해 파악하려 하지 않고 오로지 소송법적 요소에 의해 파악하여야 한다는 견해이다. 이는 소송물을 신청(우리 법상의 청구의 취지에 해당된다)만으로(일분지설, 일원설) 또는 신청과 사실관계(즉 신청을 이유 있게 하기 위해 제출된 청구원인의 사실관계²⁴⁾로서 우리 법상의 청구의 원인에 해당된다)로 식별 내지 구성하자는 견해(이분지설, 이원설)로서 이에 따라 소송물의 단복·이동이 결정된다는 것이다. 이에 의하면 실체법상의 권리 내지 법률관계는 소송물의 식별기준이 아니고 소송물이 이유있는지의 여부를 판단하는데 전제가 되는 법률적 관점 내지 공격방어방법에 지나지 않는다고 한다. 그 결과 동일한 급부 또는 동일한 법률관계의 형성을

23) 이시윤, 앞의 책, 203면.

24) 이시윤, 앞의 책, 204면; 여기서의 사실관계는 실체법상의 권리의 발생원인사실 즉 개개의 법규의 요건사실로 좁혀서 보지 않고 이보다 넓은 것으로 '사회적, 역사적으로 볼 때 하나이다'라고 할 일련의 사실관계를 뜻한다고 한다.

목적으로 하는 실체법상의 권리가 경합된 경우 이들 권리는 소송물을 이유 있게 하는 법률적 관점 내지 공격방어방법이 경합된 것에 불과하며 소송물이 여러 개인 것이 아니라고 본다. 이 점에서 신소송물이론은 구소송물이론과 본질적으로 구별된다. 예컨대 기차사고를 당한 피해자가 손해배상청구를 하면서 불법행위와 운송계약불이행이라는 두 가지 법률요건에 기하여 청구하는 경우에 있어서 소송물은 원고가 소송을 통해서 얻고자 하는 목적인 손해배상청구 하나 일 뿐이고 여기에 이를 이유 있게 하기 위한 2가지의 법률적 관점이 경합되어 있을 뿐이라는 것이다.²⁵⁾ 신소송물이론은 구소송물이론에 비하여 소송물의 크기를 확대시킴으로써 기판력의 물적 범위를 확장시키고 그 결과 분쟁을 한 번에 해결할 수 있게 해 줄 뿐만 아니라 집중심리주의 방식에 의한 소송진행에도 적합하다는 장점이 있다. 한 때 소수설에 지나지 않았으나 현재는 우리나라의 많은 학자들이 지지하여 다수설화 되었다.²⁶⁾

2) 이분지설

25) 따라서 실체법상의 권리가 경합된 경우 원고가 같은 청구취지의 소송을 하나의 사실관계에 입각하여 청구하면, 계속 중인 소송절차에서 여러 개의 실체법상의 권리를 주장하더라도 청구의 병합이 아니고, 종전에 주장하던 실체법상의 권리와 다른 실체법상의 권리로 바꾸어 주장해도 소(청구)의 변경이 되지 않으며, 소송계속 중에 다른 실체법상의 권리에 기하여 신소를 제기하면 전소와 소송물이 같은 것으로 취급되므로 중복소송이 되고 따라서 판결이 확정된 후 전소와 다른 실체법상의 권리에 기하여 다시 후소를 제기할 경우 기판력에 저촉되지 않으며 또한 원고가 주장하지 않은 다른 실체법상의 권리에 기하여 심판을 하더라도 처분권주의에 위배되지 않는 것으로 된다.

26) 이시윤, 앞의 책, 205면; 정동운·유병현, 앞의 책, 237면; 오시영, 앞의 책, 328면; 김용진, 앞의 책, 147면; 김홍규, 앞의 책, 200면 이하; 강현중, 민사소송법, 박영사, 2002, 329면.

청구의 취지와 청구원인의 사실관계를 기준으로 소송물이 특정 내지 식별된다고 하면서 청구의 취지가 다르면 소송물이 다르고 예컨대, 일정한 금전지급청구를 어음발행행위와 그 원인행위인 소비대차계약에 기하여 청구하는 경우나 소유권이전등기청구를 매매계약과 취득시효완성에 기하여 청구하는 경우와 같이 청구의 취지가 동일하다 하더라도 여러 개의 사실관계에 기하여 즉 별개인 사실관계에 기하여 청구되는 경우에는 소송물이 별개로 된다고 한다. 또한 하나의 소비대차계약에 기하여 원금과 이자를 함께 청구하는 경우와 같이 사실관계가 같더라도 청구의 취지가 다르면 청구의 병합이 되고 청구취지가 변경되는 경우는 물론이고 청구원인의 사실관계만 변경되어도 소의 변경이 되며 소송계속 중 신소가 제기된 경우 청구의 취지뿐만 아니라 사실관계까지 같아야 중복제소에 해당되고 기판력이 발생한 전소와 청구의 취지 및 사실관계가 동일한 후소를 제기하면 이는 기판력에 저촉되게 되지만 기판력이 발생한 전소와 청구의 취지나 사실관계를 달리하여 후소를 제기하면 전소의 기판력에 저촉되지 않게 된다. 결국 이분지설은 하나의 사실관계에 기하여 실체법상의 권리가 경합하는 경우에 소송물은 하나이지만 여러 개의 사실관계에 기하여 실체법상의 권리가 경합하는 경우 즉 여러 개의 사실관계에서 동일한 목적을 달성하기 위한 여러 개의 실체법상의 권리가 발생한 경우에 있어서의 소송물은 사실관계의 수만큼 여러 개가 된다는 것이다. 이와 같이 이분지설에 의하면 사실관계에 의하여 소송물이 식별되므로 기판력의 범위도 그 만큼 좁아지게 되어 아래에서 보는 일본지설에서와 같은 단점을 피할 수 있으나 사실관계라고 하는 모호한 개념을 소송물의 구성요소로 함으로써 그 한계확정이 어렵다는 비판을 받고 있다.²⁷⁾

27) 이시윤, 앞의 책, 204면; 김용진, 앞의 책, 146면.

3) 일본지설

이분지설에서 소송물의 식별기준으로 내세우는 사실관계라는 개념의 모호성 내지 불확정성을 비판하면서 청구원인의 사실관계는 소송물의 구성요소가 아니고 오직 신청(우리 법상의 청구의 취지)만이 소송물의 구성요소이고 이에 의해 소송물이 식별된다고 한다. 즉 원고가 소로써 달성하고자 하는 사회적, 경제적 목적이 표시된 것이 바로 청구의 취지이므로 소송물의 단복·이동은 청구의 취지의 단복·이동에 따라 결정된다고 한다. 구체적으로 이행의 소에 있어서의 소송물은 원고가 피고에 대해 '이행을 구하는 법적 지위(수급권)의 주장'이고 형성의 소의 경우에는 '형성을 구하는 법적 지위의 주장'이 소송물이며 확인의 소의 소송물은 '구체적인 권리 또는 법률관계의 주장'으로써 각 그 동일성에 의하여 소송물이 특정된다고 한다.²⁸⁾ 이는 소송물의 범위를 가장 넓게 인정하는 입장으로 청구의 취지가 하나이면 사실관계가 여러 개라 하더라도 소송물은 하나일 뿐이라고 한다. 다만, 예외적으로 금전지급청구나 대체물지급청구의 경우에는 소송물의 단복·이동의 식별을 위하여 청구원인의 사실관계를 참작하여야 하며 이 경우에는 청구원인의 사실관계에 의하여 비로소 소송물이 특정된다고 본다.²⁹⁾ 그러나 이에 의하면 여러 개의 사실관계에서 동일한 목적을 달성하기 위한 여러 개의 실체법상의 권리가 발생한 경우에 있어서도 소송물은 하나이고 단지 공격방어방법만이 복수인 것이라고 보게 되어 이 경우 원고가 승소한 경우는 물론이고 패소한 경우에도 법원에 제출되지 않은 실체법상의 권리가 기판력에 의해 차단되는 결과 기판력이 미치는 범위가 너무 넓어져 패소한 당사자에게 가혹하다는 비판을 받고 있다.³⁰⁾

28) 新堂幸司, 新民事訴訟法, 弘文堂, 1998, 270면.

29) 이시윤, 앞의 책, 205면.

(3) 신실채법설과 기판력의 범위

1) 신실채법설은 구소송물이론과 신소송물이론의 이론적 대립을 해소하고자 등장한 것으로서 실체법상 청구권의 개념 자체를 수정하여 수정된 의미의 실체법상 청구권의 주장을 소송물로 보는 견해이다. 즉 하나의 생활사실이 여러 개의 실체법규가 정해 놓은 요건에 해당된다 하더라도 이에 관해 실체법질서가 하나 또는 1회의 급부만을 허용해 놓고 있는 것에 불과한 경우에는 여러 개의 실체법규(청구법규)에 기한 하나의 통일된 실체법상의 청구권만이 발생하는 것이며 이것이 바로 소송물이라는 것이다.³⁰⁾ 신실채법설은 종래 전통적으로 청구권이 경합되어 있는 것으로 보아 온 여러 사례에 대하여 이는 청구법규가 경합된 것에 지나지 않는 것으로서 실체법질서가 1회의 급부만을 허용하고 있는 경우이므로 하나의 통일적 청구권(소송물)만이 존재한다고 한다. 다만 여러 개의 사실관계로부터 여러 개의 청구권이

30) 이에 대해 이시윤, 앞의 책, 536면에는 우리의 일본지설은 일본의 그것과는 다르다고 하면서 기판력의 대상은 제출된 사실관계를 토대로 한 원고 주장의 법률효과의 존부에 관한 판단이므로 위와 같은 경우는 사실관계가 전소와는 전혀 달라 별개의 소송물이 되므로 기판력에 의해 실권되지 않는다고 하고 있다. 결국 우리의 일본지설은 청구의 취지만으로 소송물을 확정하여야 한다면서도 기판력의 물적 범위에 관해서만은 이분지설과 같은 입장을 취하는 것으로 보인다. 다만, 독일의 경우 ZPO 제322조 제1항에서 기판력의 물적 범위를 우리나라와 같이 판결주문을 단위로 하지 않고서 “판결은 소 또는 반소로서 제기한 청구에 관하여 재판한 부분에 한하여 기판력이 있다”(Urteile sind Rechtskraft nur insoweit fähig, als über den durch die Klage oder durch die Widerklage erhobenen Anspruch entschieden ist.)라고 규정하고 있기 때문에 일본지설의 입장에서 기판력의 물적 범위를 정함에 있어서 당사자가 주장하거나 제출한 사실관계를 참작함으로써 이분지설에 가까운 입장을 따르고 있다.

31) 하나의 사실관계에서는 하나의 실체법상이 청구권(통일적 청구권)만이 발생되고 허용되며 이러한 급부를 구할 수 있는 법적 지위(급부요구권) 그 자체가 바로 소송물이라는 것이다.

발생하는 경우에는 청구권이 경합되고 소송물이 복수가 된다고 한다.³²⁾

2) 이에 의하면 청구법규가 경합된 경우³³⁾ 하나의 실체법상의 청구권만이 존재하는 것으로 되므로 이 경우 청구법규만을 달리하여 후소를 제기하게 되면 전소의 기판력에 저촉되게 된다. 즉 법원이 경합하는 청구법규 중 하나만을 참작하여 원고 패소판결이 확정되어 기판력이 발생하면 다른 청구법규를 들어 후소로 다룰 수 없게 된다. ~~반면 청구권 경합의 경우는 소송물이 복수가 되므로 하나의 청구권에 대한 기판력은 다른 청구권에 미치지 않게 된다.~~ 그러나 신실채법설에 의해서는 소멸시효, 증명책임의 분배 및 경합하는 법규 사이의 적용순위 등의 문제를 해결할 수 없다는 비판을 받고 있다.³⁴⁾

4. 판례의 태도 및 이에 대한 검토

(1) 우리 판례의 주류는 구소송물이론의 입장에 서서 청구원인에 의하여 특정되는 실체법상의 권리 또는 법률관계에 관한 주장을 소송물로 보고 청구원인에 의해 그 동일성 내지 단복·이동이 식별된다고 하여³⁵⁾ 소송물을 지나치게 좁게 파악하고 있고 그 결과 기판력의 물적 범위도 너무 좁아지게 된다는 비판을 받고 있다.³⁶⁾ 판례는 매때 (또는 대물변제)를 청구원인으로 한 소유권이전등기청구사건의 판결

32) 정동윤·유병현, 앞의 책, 235면

33) 전통적 의미의 청구권경합의 경우를 말한다.

34) 이시윤, 앞의 책, 207면; Arens, Zur Anspruchskonkurrenz bei mehreren Haftungsgründen, AcP 170(1970), 392ff.

35) 대판 1969. 12. 16, 65다2363; 대판 1989. 3. 28, 88다1936.

36) 그 결과 동일한 사실관계임에도 후소에서 약간의 법률적 관점만을 달리 하면 기판력을 받지 않게 되므로 분쟁의 1회적 해결에 반하고 법적 안정성을 해치게 된다는 것이다.

의 기판력은 그 후 취득시효를 청구원인으로 한 소유권이전등기청구 사건에는 미치지 않으나,³⁷⁾ 다만, 소유권이전등기말소등기 청구사건의 소송물은 당해 등기의 말소등기청구권이고³⁸⁾ 그 동일성 식별의 표준이 되는 청구원인, 즉 말소등기청구권의 발생원인은 당해 “등기원인의 무효”에 국한되므로, 전소에서 한 사기에 의한 매매의 취소 주장과 후소에서 한 매매의 부존재 또는 불성립의 주장은 다 같이 청구원인인 등기원인의 무효를 뒷받침하는 독립된 공격방어방법에 불과하므로 전소의 기판력은 후소에 미친다고 한다.³⁹⁾ 또한 같은 입장에서 부당이득반환청구사건에 있어서 원고가 법률상 원인 없는 사유로써 계약의 취소, 무효, 불성립, 해제 등을 주장하는 것은 공격방어방법에 불과한 것이므로 그 중 어느 사유를 주장하여 패소가 확정된 경우에 다른 사유에 기하여 신소를 제기함은 기판력에 저촉된다고 한다.⁴⁰⁾ 판례는 기판력은 주문에 포함된 소송물인 법률관계의 존부에 관한 판단의 결론에 대하여서만 생기는 것이어서, 소유권이전등기절차의 이행을 명한 확정판결의 기판력은 소송물인 그 이전등기청구권의 존부에만 미치고 소송물이 되어 있지 않은 소유권의 귀속 자체에까지 미치는 것

37) 대판 1968. 3. 19, 68다123; 대판 1991. 1. 15, 88다카19002, 19010. 그 밖에 소유권이전등기청구소송에서 청구원인을 대물변제계약과 매매계약 또는 매매와 다른 약정으로 한 경우 역시 소송물이 각 별개라고 보고 있다(대판 1997. 4. 25, 96다32133; 대판 1996. 8. 23, 94다49922).

38) 따라서 이에 대한 판결의 기판력은 소유권에 미치지 않는다(대판 1971. 5. 24, 71다632). 토지소유권에 기한 지상건물철거소송에 있어서의 소송물은 철거청구권 즉, 소유권에 기한 방해배제청구권이며 상대방이 철거를 구하는 지상건물의 소유자라던가 점유자라는 주장은 소송물과 관계없이 철거청구권의 행사를 이유 있게 하기 위한 공격방어방법에 불과하다고 한다(대판 1985. 3. 26, 84다카 2001).

39) 대판 1993. 6. 29, 93다11050; 대판 1981. 12. 22, 80다1548. 이에 따라 무권대리, 불공정한 법률행위 등의 주장 역시 원인무효를 뒷받침하는 공격방어방법으로서 기판력에 저촉된다 할 것이다.

40) 대판 2000. 5. 12, 2000다5978.

은 아니므로, 소유권이전등기청구 소송을 제기당하여 패소한 당사자도 그 이후 소유권이전등기를 경료한 등기 명의자를 상대로 다시 소유권확인을 구하거나 진정한 소유자 명의의 회복(진정명의회복)을 위한 소유권이전등기를 구하는 소송을 제기할 수 있다고 하고 있고⁴¹⁾ 채권, 채무의 존부에 관한 청구와 그 채권, 채무관계를 원인으로 한 등기의 말소청구권의 존부는 별개의 소송물이므로 채무부존재확인 및 확정판결의 기판력은 그 채무부존재를 원인으로 하는 등기 말소청구소송에 미칠 수 없다고 한다.⁴²⁾ 또한 판례는 특정토지에 대한 소유권확인의 본안판결이 확정되면 그에 대한 권리 또는 법률관계가 그대로 확정되는 것이므로 그 사건의 변론종결 전에 그 확인원인이 되는 다른 사실이 있었다 하더라도 그 확정판결의 기판력은 거기까지도 미치는 것으로써 실사 그 사건의 변론종결 전에 피고가 그 토지를 매수하였거나 취득시효의 완성으로 소유권을 취득하였다 하더라도 그와 같은 사유만으로는 위 확정판결의 기판력을 배제할 수 없다고 한다.⁴³⁾ 그 밖에 판례는 재심의 소에 있어서 재심사유는 개개의 재심사유가 독립된 것으로서 어느 한 가지 사유를 들어 재심의 소를 제기하였다가 패소판결이 확정되었다고 하더라도 다른 재심사유가 있는 경우에는 그 재심사유로써 다시 재심의 소를 제기할 수 있다⁴⁴⁾고 하여 소송물을 재심사유마다 별개로 보고 있고, 이혼소송에 있어서도 민법

41) 대판 1997. 6. 27, 97다9529; 대판 2002. 9. 24, 2002다11847

42) 대판 1980. 9. 9, 80다1020; 그러나 이 경우 채무부존재확인소송은 그 채무부존재를 원인으로 한 등기말소청구소송과 선결적 권리관계에 있으므로 위 등기말소청구소송에서는 채무부존재부분에 관한 전소의 기판력이 미친다고 보는 것이 타당하다고 생각한다.

43) 대판 1987. 3. 10, 84다카2132; 이 경우 매수나 시효취득의 주장은 공격방어방법에 불과하여 기판력의 차단효 내지 실권효가 미치게 된다는 것이다.

44) 대판 1970. 1. 27, 69다1888.

제840조 소정의 각 사유마다 독립된 이혼청구원인이 되므로(즉 별개의 소송물이 되므로) 법원은 원고가 주장한 이혼사유에 관하여서만 심판하여야 한다고 하고 있다.⁴⁵⁾ 그 결과 원고는 전소에서 패소하더라도 변론종결 전의 다른 이혼사유에 기하여 후소를 청구할 수 있게 된다.

(2) 그러나 최근에 이르러 구소송물이론에 입각해 오던 판례의 태도는 약간의 동요를 보이면서 소송물의 개념을 넓게 파악하고 있는데 1) 회사의 총회결의에 대한 부존재확인청구나 무효확인청구는 모두 법률상 유효한 결의의 효과가 현재 존재하지 아니함을 확인받고자 하는 점에서 동일한 것이라고 하고 있음⁴⁶⁾과 아울러 위 양자의 소송물이 공동된다는 전제하에 동일한 주주총회결의에 관하여 부존재확인 소가 상법 제376조 소정의 제소기간 내에 제기되어 있다면, 동일한 하자를 원인으로 하여 결의의 날로부터 2월의 제소기간이 경과한 후에 취소소송으로 소를 변경하거나 추가한 경우에도 부존재확인 소 제기 시에 제기된 것과 동일하게 취급하여 제소기간을 준수한 것으로 보아야 한다고 하고 있고,⁴⁷⁾ 2) 신체상해로 인한 손해배상청구의 경우에 제1심에서 재산상 손해에 대하여는 전부 승소하였으나 위자료에 대하여는 일부 패소한 원고가 패소한 위자료 부분에 관하여만 항소하였더라도 항소심에서 재산상 손해에 대하여도 청구의 확장을 할 수 있다고 하고 있으며,⁴⁸⁾ 3) 과세처분무효확인소송의 경우에 무효사유

45) 대판 1963. 1. 31, 62다812; 대판 2000. 9. 5, 99므1886.

46) 대판 1983. 3. 22, 82다카1810.

47) 대판 2003. 7. 11, 2001다45584; 이는 철저한 구소송물이론의 입장을 일부 완화한 것으로 볼 수 있다.

48) 대판 1994. 6. 28, 94다3063; 이는 원고가 재산상 손해에 대하여는 형식상 전부 승소하였으나 위자료에 대하여는 일부 패소하였고, 이에 대하여 원고가 원고 패소부분에 불복하는 형식으로 항소를 제기하여 사건 전부가 확정이 차단되고 소송물 전부가 항소심에 계속되게 되었고, 더욱이 불법

로 내세운 개개의 주장은 공격방법에 불과하고 이 경우의 소송물은 무효확인을 구하는 것이라고 하고 있다.⁴⁹⁾ (3) 특히 판례는 진정명의 회복을 위한 소유권이전등기청구소송과 관련하여,

1) 전소인 소유권이전등기말소청구소송의 원고 또는 피고로서 패소 확정된 자가 후소로서 진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구소송을 제기한 경우 부동산에 관한 소유권이전등기가 원인무효라는 이유로 그 등기의 말소를 구하는 소송의 기판력은 그 소송물이었던 소유권이전등기말소 등기청구권의 존부에만 미치는 것이고 그 전제가 되는 소유권 자체의 존부에는 미치는 것이 아니므로 소유권이전등기말소청구소송에서 패소한 당사자도 그 후 다시 소유권확인을 구하거나 진정한 소유자 명의의 회복을 위한 소유권이전등기를 구하는 소송을 제기할 수 있다고⁵⁰⁾ 하였으나 최근에는 입장을 바꾸었다. 즉 진정한 등기명의의 회복을 위한 소유권이전등기청구는 이미 자기 앞으로 소유권을 표상하는 등기가 되어 있었거나 법률에 의하여 소유권을 취득한 자가 진정한 등기명의를 회복하기 위한 방법으로 현재의 등기명의인을 상대로 그 등기의 말소를 구하는 것에 갈음하여 허용되는 것인데, 말소등기에 갈음하여 허용되는 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기청구권과 무효등기의 말소청구권은 어느 것이나 진정한 소유자의 등기명의를 회복하기 위한 것으로서 실질적으로 그 목적이 동일하고, 두 청구권 모두 소유권에 기한 방해배제청구권으로서 그 법

행위로 인한 손해배상에 있어 재산상 손해나 위자료는 단일한 원인에 근거한 것인데 편의상 이를 별개의 소송물로 분류하고 있는 것에 지나지 않기 때문이라고 한다.

49) 대판 1992. 2. 25, 91누6108.

50) 대판 1990. 11. 27, 89다카 12398; 대판 1990. 12. 21, 88다카26482; 대판 1993. 7. 27, 92다50072. 이에 따르면 부동산의 소유명의를 다투는 소송에서 한번 승소한 당사자로 하여금 또 다시 소송에 휘말리게 하는 결과를 낳게 되어 법적 안정성을 심히 침해하게 된다는 문제가 있었다.

적 근거와 성질이 동일하므로, 비록 전자는 이전등기, 후자는 말소등기의 형식을 취하고 있다고 하더라도 그 소송물은 실질상 동일한 것으로 보아야 하고, 따라서 소유권이전등기말소 청구소송에서 패소확정판결을 받았다면 그 기판력은 그 후 제기된 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기 청구소송에도 미친다고 하고 있다.⁵¹⁾

이러한 판례의 태도에 대하여는 ① 위 판결에서는 양 소송의 목적, 법적 근거 및 성질의 동일성을 들어 양 소송의 소송물이 동일한 것으로 이해하고 있으나, 판례가 취하고 있는 구소송물이론, 즉 소송물이 청구취지와 청구원인에 의하여 특정된다고 보는 입장에서 보면 위 판결에서 소송물의 동일성 여부에 관한 식별기준으로 언급하고 있는 소송의 목적, 법적 근거 및 성질은 새로운 식별기준의 제시로 이해될 수 있어 기존의 판례의 태도와 관련하여 어떻게 조화롭게 이해할 것인지 매우 심각한 문제점을 제시하고 있으며 위와같은 새로운 기준은 너무 애매하고 취약하여 통일적으로 체계적인 소송물의 식별기준으로서는 미흡하다고 보는 견해,⁵²⁾ ② 진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구권은 계약에서 나온 청구권이 아니라 소유권의 효력에서 나온 물권적 청구권이므로, 소유자가 이미 종전 판결의 기판력으로 인하여 더 이상 말소등기를 청구할 수 없는 경우에는 동일한 당사자를 상대로 소유권에 기한 진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구도 할 수 없다고 보아야 한다면서 위 판결에 의문을 제기하는 견해,⁵³⁾ ③ 말소등기에 갈음하는 진정명의회복을 위한 이전등기의 청구소송과 말소등

기청구소송은 외형적인 청구취지 및 청구원인의 상이에도 불구하고 실질적 목적이 동일하고 법적 성질이 동일하므로 양소의 소송물은 실질상 동일한 것으로 봄이 상당하다고 하면서 위 판결에 찬성하는 견해,⁵⁴⁾ ④ 말소등기청구권과 진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구권은 소유권에 기한 방해배제청구권으로서 그 발생근거(실체법상의 적용법조)와 본질에 있어서 동일하고 등기의 형식이 다를 뿐이므로 양자의 청구소송 역시 그 소송물이 동일하다고 하면서, 양자의 청구소송의 실질이 어떠한 형식상 청구취지 자체가 다르므로 소송물이 다른 것으로 보아야 한다는 주장은 소송물의 동일 내지 청구취지의 동일 여부를 지나치게 형식적으로 파악한 것으로서 부당하다고 하는 견해,⁵⁵⁾ ⑤ 원인무효로 인한 말소등기청구는 그 전 등기로의 회복을 목적으로 하는 소극적인 것임에 반하여 소유권이전등기는 새로운 등기의 생성을 목적으로 하는 적극적인 것이라는 점에서 그저 소유권 방해배제를 위한 것이라 하여 한 대로 묶어 버릴 수만은 없는 것으로써 말소등기청구권과는 별도의 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기청구권을 인정하지 않을 수 없고 양자는 실질적으로나 형식적으로나 별개의 청구권, 별개의 소송물이 될 수 있다고 보는 견해,⁵⁶⁾ ⑥ 위 판결에서 양 소송을 실질적으로 동일한 것으로 본 이유는 말소등기청구소송에서 패소한 자가 실질상 동일한 분쟁을 이전등기청구소송을 통하여 재연하려는 것을 막기 위하여 기판력을 이용하고자 한 것으로 파악한 뒤 이 경우 전소와 후소는 청구취지가 다르므로 어떠한

51) 대판 2001. 9. 20, 99다37894; 대판 2003. 3. 28, 2000다24856.

52) 김홍엽, “소유권이전등기의 말소등기청구소송과 진정명의회복을 위한 이전등기청구소송에 있어서 기판력의 문제”, 법조통권544권, 2002. 1, 187면.

53) 김재형, “진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구의 허용범위”, 김용준 헌법재판소장 회갑기념, 재판의 한길, 342면.

54) 이충상, “진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구와 기판력”, 저스티스 통권 66호, 155면.

55) 김오수, “진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구와 기판력의 문제”, 민사재판의 체문제 제9권, 278면.

56) 김황식, “진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구의 당부”, 민사판례연구 IV, 44면.

소송물이론에 의하더라도 소송물은 다르다고 하면서 다만 양 소송의 소송물이 실질적으로 동일하여 모순된 반대관계에 해당하므로 전소 판결의 기판력이 후소에 미친다고 보아야 한다는 견해⁵⁷⁾ 등 여러 견해가 현출되어 있는 바, 무엇보다도 전후 양소의 기판력에 관한 문제는 궁극적으로 소송물이론과 관련되어 소송물의 본질을 어떻게 파악할 것인지와 직결되고 종래 판례가 구소송물이론을 취하고 있기 때문에 신소송물이론과의 관계에서 논란이 재연될 여지가 있다고 생각한다.⁵⁸⁾

2) 또한 판례는 전소인 소유권이전등기청구소송의 피고로서 패소한 자가 전소원고를 상대로 후소로서 진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구소송을 제기한 경우 위 양 소의 소송물이 별개임을 전제로 이를 허용하여 왔으나⁵⁹⁾ 위 99다37894 판결 이후로는 후소의 소송물이 전소의 그것과 동일한 것은 아니라고 하더라도 전소에서 확정된 권리관계와 정면으로 모순되는 반대의 사항을 소송물로 삼은 경우에는 확정된 전소판결의 기판력이 미치게 됨을 이유로 이는 허용되지 않는다고 하고 있다. 즉 제소전 화해조서에 기하여 소유권이전등기절차가 마쳐진 부동산에 관하여 이전등기말소청구와 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기청구가 선택적으로 병합되어 제기된 사건에서 전후 양 소의 소송물이 동일하지 않다고 하더라도, 후소의 소송물이 전소에서 확정된 법률관계와 모순되는 정반대의 사항을 소송물로 삼았다면 이러한 경우에는 전소 판결의 기판력이 후소에 미치는 것이고, 소유권이전등기절차를 이행하기로 한 제소 전 화해가 준재심에

의하여 취소되지 않은 이상, 그 제소 전 화해에 기하여 마쳐진 소유권이전등기가 원인무효라고 주장하며 말소등기절차의 이행을 청구하는 것은 제소 전 화해의 기판력에 저촉되고 말소등기청구에 갈음하여 허용되는 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기청구 역시 진정한 소유자의 등기명의를 회복하기 위한 것으로서 말소등기청구와 그 소송물이 실질상 동일한 것으로 보아야 하므로 그 역시 제소 전 화해의 기판력에 저촉되는 것이라고 하고 있는데⁶⁰⁾ 이러한 판례의 입장을 정리하면 전소인 소유권이전등기말소청구소송에서 패소 확정된 자는 그가 원고이든 피고이든 후소로써 진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구를 하는 것이 전소판결의 기판력에 저촉되어 허용되지 않게 되고, 전소인 소유권이전등기청구소송에서 패소 확정된 피고가 전소 원고를 상대로 후소로 진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구를 하는 것 역시 기판력에 저촉되는 것이 된다.

3) 다만, 판례는 전소인 소유권이전등기청구소송의 피고로서 패소 확정된 자가 최종등기명의인을 상대로 후소로서 소유권확인 및 진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구를 한 경우에 있어서, 확정판결의 기판력은 그 판결의 주문에 포함된 것 즉 소송물로 주장된 법률관계의 존부에 관한 판단의 결론 그 자체에만 생기는 것으로 부동산소유권이전등기절차의 이행청구에 관한 확정판결의 기판력은 그 소송물이었던 이전등기청구권의 존부에만 미치고 그 목적 부동산의 소유권 자체의 존부에 까지 미치는 것은 아니므로 소유권이전등기청구소송에

57) 유병현, “기판력과 진정명의회복을 위한 소유권이전등기소송”, 고려법학 제39호, 2002. 11, 307면 이하.

58) 홍기문, “소송물이론에 관한 소고”, 민사소송, 2006, 29면.

59) 대판 1993. 7. 27, 92다50072; 2000. 6. 9, 98다28947, 28954; 2001. 10. 12, 2001다15866, 15873.

60) 대판 2002. 12. 6, 2002다44014; 2002. 12. 26, 2002다26061. 이는 후소의 소송물이 전소의 그것과 동일한 것은 아니라고 하더라도 전소에서 확정된 권리관계와 정면으로 모순되는 정반대의 사항을 소송물로 삼은 경우에는 확정된 전소판결의 기판력이 미치게 됨을 전제로 하고 있는 것으로 보인다. 송명호, “기판력의 문제를 중심으로 한 진정명의회복을 위한 소유권이전등기에 관한 고찰”, 법조 52권 11호, 2003. 11, 165면 이하.

서 패소한 당사자도 그 후 진정한 소유자 명의의 회복을 위한 소유권이전등기를 청구할 수 있다고 하고 있고,⁶¹⁾ 또한 전소인 소유권이전등기말소청구소송이나 진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구소송에서 패소 확정된 자가 후소로서 소유권확인청구소송을 제기한 경우, 각 확정판결의 기판력은 소송물로 주장된 말소등기청구권이나 이전등기청구권의 존부에만 미치지 그 기본이 된 소유권 자체의 존부에는 미치지 않으므로 확인을 구할 법률상의 이익이 있다고 하고 있다.⁶²⁾

(4) 그 밖에 가분채권의 일부청구⁶³⁾의 경우에 있어서 일부청구에 대한 확정판결의 기판력이 잔부청구에 대해서도 미치는 것인지에 관하여 판례는 명시적 일부청구의 경우와 묵시적 일부청구의 경우를 구별하여 전자의 경우에는 소송물은 그 일부이므로 잔부에 대하여는 기판력이 미치지 아니하나 후자의 경우에는 소송물은 그 전부이므로 잔부청구를 하는 것은 기판력에 저촉되어 부적법하다고 하고 있다.⁶⁴⁾ 이와 관련하여 불법행위에 기한 손해배상청구소송의 판결이 확정되어 기판력이 발생한 후 후소로써 당초 그 소송에서 예견할 수 없었던 후유증의 발생으로 인해 확대된 손해에 대한 배상청구를 한 경우 판례는 불법행위로 인한 적극적 손해의 배상을 명한 전소송의 변론종결 후에 새로운 적극적 손해가 발생한 경우에 그 소송의 변론종결당시 그 손해의 발생을 예견할 수 없었고 또 그 부분 청구를 포기하였다고 볼 수 없는 등 특별한 사정이 있다면 전 소송에서 그 부분에 관한 청

61) 대판 1997. 5. 16, 96다43799.

62) 대판 1992. 11. 10, 92다22121; 대판 1999. 7. 27, 99다980; 대판 2002. 9. 24, 2002다11847. 이는 선결적 법률관계에 관하여는 기판력이 미치지 않는다는 것을 전제로 하고 있는 것이다.

63) 일부청구는 소송물이론과 필연적인 관계가 있는 것은 아니며 소권의 남용에 해당되는 경우를 제외하고 그것이 허용된다는 것이 통설 및 판례의 태도이다.

64) 대판 1989. 6. 27, 87다카2478; 대판 2000. 2. 11, 99다10424.

구가 유보되어 있지 않다고 하더라도 이는 전 소송의 소송물과는 별개의 소송물이므로 전 소송의 기판력에 저촉되는 것이 아니라고 하고 있다.⁶⁵⁾

Ⅲ. 판결이유 중의 판단

1. 원 칙

법 제216조 제1항의 반대해석상 판결이유 중의 판단에 관하여는 상계의 항변을 제외하고 기판력이 생기지 않는 것이 원칙이고 그 이유는 앞서 총설에서 살펴본 바와 같다. 따라서 판결이유 중에서 판단된 사실,⁶⁶⁾ 선결적 법률관계, 항변⁶⁷⁾ 또는 법률판단⁶⁸⁾에 대해서는 기판

65) 대판 1980. 11. 25, 80다1671; 이 경우 그 근거로 일부청구이론을 원용하지는 입장 <最高裁判所 昭和 42(1967). 7. 18, 民集 21卷 6号, 1559면; 最高裁判所 昭和 61(1986). 7. 17, 民集 40卷 5号, 941면>과 기판력의 시적 한계를 벗어나는 것 또는 기대가능성의 문제로 파악하자는 견해(秋山幹男 의 5人, 앞의 책, 466면)도 있으나 판례와 같이 소송 계속 중에 당사자에게 그 제출을 기대할 수 없었던 사실자료에 관하여는 전소판결의 기판력이 미치지 아니하고 후유증에 따른 손해는 표준시 뒤에 발생한 새로운 사유로 인한 손해로서 그 소송물은 전소의 소송물과는 별개의 소송물이라고 파악하는 것이 통설이다.

66) 예컨대, 대리권의 유무에 관한 사실인정, 손해배상청구소송에서의 고의, 과실, 인과관계의 유무 등.

67) 예컨대, 토지인도청구가 피고의 임차권의 존재를 이유로 기각된 경우 임차권의 존재에 관한 판단에는 기판력이 생기지 않고 토지인도청구에 대한 동시이행판결이 선고된 경우 동시이행항변으로 제출한 반대채권의 존재에 관하여는 기판력이 생기지 않는다. 대판 1975. 10. 21, 75다48; 같은 취지로 상계 주장의 대상이 된 수동채권이 동시이행항변으로 행사된 채권일 경우, 그러한 상계 주장에 대한 법원의 판단에는 기판력이 생기지 않는다. 대판 2005. 7. 22, 2004다17207.

68) 법규의 해석 및 구체적 사실에 대한 법규의 적용을 포함하는데 예컨대, 매매계약이 무효라거나 농지매매가 무효라고 하는 판단에는 기판력이 생

력이 생기지 않음이 원칙이다.⁶⁹⁾

2. 문제점과 해결방법론

(1) 판결이유 중의 판단에 관하여는 기판력이 생기지 않는다는 원칙에 의하면 판결이유 중에 특히 소송물인 권리 또는 권리관계의 존부를 판단함에 있어 전제가 되는 선결적 법률관계의 존부가 판단되어 있더라도 이에 관하여는 기판력이 생기지 않게 된다.⁷⁰⁾ 그 결과 매매대금청구나 건물명도청구에 있어서는 매매대금청구권이나 건물명도청구권의 존부가 소송물이고 그 청구권 판단의 전제가 되는 매매나 건물소유권의 존부에 대한 판단에는 기판력이 생기지 않게 되므로 이에 대해 기판력을 생기게 하기 위해서는 중간확인의 소 또는 별소를 제기할 수밖에 없다는 것이 된다. 그러나 당사자에게 중간확인의 소의 제기를 강요할 수 없고 또한 당사자의 주된 관심사가 되는 것은 통상 소송물에 관한 법원의 판단일 뿐 선결적 법률관계는 그 수단에 불과하기 때문에 소송계속 중의 당사자가 그에 관해 별소를 제기하여 기판력 있는 판결을 받는다는 것은 대단히 이례적인 것이 된다. 그 결과 법원이 소송물에 관하여 종국적인 판단을 하였음에도 불구하고 분쟁은 완전히 해결되지 않고 계속 반복될 가능성이 상존하게 되는데⁷¹⁾

가지 않는다. 대판 1968. 9. 30, 68다1411.

69) 그러나 이러한 원칙은 논리적으로 필연적인 것은 아니고 오히려 영미에서는 일찍부터 금반언(estoppel)의 원칙에 의하여 판결주문뿐만 아니라 판결이유 중의 판단에 관해서도 쟁점배제효(issue preclusion)라 하여 일정한 구속력을 인정하고 있다.

70) 대판 1972. 10. 10, 72다1430; 대판 1982. 3. 9, 81다464; 대판 2003. 3. 28, 2000다24856; 대판 2005. 12. 23, 2004다55698 등.

71) 예컨대, 갑이 을을 상대로 소유권에 기한 건물명도청구소송을 제기하여 승소확정판결을 받더라도 판결이유 중에서 판단된 소유권의 존재에 관하여는 기판력이 생기지 않게 되므로 을은 갑의 소유권을 부인하면서 그

이는 소송경제라는 민사소송의 이상에 반하는 것일 뿐만 아니라 기판력이 발생한 전소의 판결과 모순·저촉되는 판결이 선고됨으로써 법원에 대한 불신을 야기시킬 수도 있게 된다는 점에서 문제가 되는 것이다.

(2) 기판력의 물적 범위 = 소송물이라는 전통적 명제에 입각하여 기판력의 물적 범위를 좁게 인정함으로써 야기되는 위와 같은 문제점을 해결하기 위하여 판결이유 중의 판단에 관하여도 일정한 요건 하에 구속력을 인정하자고 하는 견해가 독일 및 일본의 여러 학자들에 의해 제기되어 있는데⁷²⁾ 독일의 Zeuner는 의미관련(Sinnzusammenhang)이라는 개념을 사용하여 전소 판결의 목적에 비추어 볼 때 후소에서 확정하려는 법적인 효과와 의미관련이 성립되면 전소의 판결이유 중의 판단에도 기판력이 미친다고 하고 있고(의미관련론), Henckel은 전소와 후소의 경제적 가치가 같은 경우에는 전소에서 판단한 선결적 법률관계에 대하여도 기판력을 인정하여야 한다고 하고 있으며(경제적 가치 동일론), 일본의 新堂幸司는 영미법상의 collateral estoppel(부수적 금반언) 또는 issue preclusion(쟁점배제효)의 법리에 기초하여 기판력은 주문에 판단된 소송물에 한하여 미치는 것이 원칙이나 판결이유 중의 판단이라도 그것이 소송에 있어서 중요한 쟁점이 되어 당사자가 주장, 입증하고 법원도 그에 관하여 실질적 심리를 한 경우에는 그 쟁점에 대해서 행한 법원의 판단에 구속력을 인정하여야 한다고 한다(쟁점효이론). 그러나 우리나라 대부분의 학자들은 위와 같은 견해에 대해 부정적인 태도를 보이면서⁷³⁾ 신의칙 즉 선행행위와 모순되

명의를 등기가 원인무효임을 주장하며 갑을 상대로 소유권이전등기말소청구소송을 제기할 수 있게 된다.

72) 자세한 것은 이시윤, 앞의 책, 539면 이하; 정동운·유병현, 앞의 책, 709면 이하 각 참조.

73) 의미관련론이나 경제적 가치 동일론은 어느 경우에 의미관련이 있고 경

는 거동금지의 원칙 또는 권리실효의 원칙 등을 적극적으로 활용하여 전소의 판결이유 중의 판단에 관하여 구속력을 인정해야 할 것이라고 하고 있다.⁷⁴⁾ 우리 판례는 쟁점효이론에 대해 부정적인 태도를 보이면서⁷⁵⁾ 이 문제를 이론바 확정판결의 증명효에 의해 해결하고자 하고 있다. 즉 전후 두개의 민사소송이 당사자가 같고 분쟁의 기초가 된 사실도 같으나 다만 소송물이 달라 기판력에 저촉되지 아니한 결과 새로운 청구를 할 수 있는 경우에 있어서 이미 확정된 전 소송에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 후 소송에서 유력한 증거자료로서의 효력(증명효)이 생긴다는 것이다.⁷⁶⁾

3. 예외(상계의 항변)

(1) 판결이유 중의 판단 가운데 현행법이 기판력을 인정하고 있는 유일한 예외는 상계의 항변이다(법 제216조 제2항). 즉 피고가 상계의 항변을 하면 피고의 자동채권(반대채권)의 존부에 관하여 판결이유 중에서 판단하게 되지만 원고의 소구채권을 소멸시키기 위하여 상계 하자고 대항한 액수의 한도 내에서 기판력이 생긴다는 것이다. 만일 이에 대하여 기판력을 인정하지 않는다면, 원고의 청구권의 존부에 대한 분쟁이 나중에 다른 소송으로 제기되는 반대채권의 존부에 대한 분쟁으로 변형됨으로써 상계 주장의 상대방은 상계를 주장한 자가 그 반대채권을 이중으로 행사하는 것에 의하여 불이익을 입을 수 있게

제적 가치가 동일하다고 할 것인지가 불분명하고 쟁점효이론 역시 이를 인정하기 위한 요건이 불명확하다고 한다.

74) 이시윤, 앞의 책, 541면; 정동윤·유병현, 앞의 책, 713면; 오시영, 앞의 책, 820면.

75) 대판 1979. 2. 13, 78다58.

76) 대판 1990. 12. 11, 90다카7545; 대판 1995. 6. 29, 94다47292; 대판 2003. 8. 19, 2001다47467.

될 뿐만 아니라 상계 주장에 대한 판단을 전제로 이루어진 원고의 청구권의 존부에 대한 전소의 판결이 결과적으로 무의미하게 될 우려가 있기 때문이다.⁷⁷⁾

(2) 상계의 항변에 관한 판단에 기판력이 생기기 위해서는 법원이 반대채권의 존부에 관하여 실질적으로 판단하였어야 하는데⁷⁸⁾ 상계의 항변이 배척된 경우이든 인용된 경우이든 가리지 않고 자동채권의 존부에 대하여는 상계로써 대항한 액수에 한하여 기판력이 생긴다. 따라서 반대채권의 부존재를 이유로 상계의 항변을 배척한 경우에는 반대채권의 부존재에 대하여 기판력이 생기고 이를 인용한 경우에는 상계로 대항한 수액에 한하여 기판력이 생길 뿐 소구채권액을 넘는 반대채권액 부분에는 기판력이 미치지 않으므로 이를 별도로 청구할 수 있다. 상계의 항변을 받아들여 원고의 청구를 기각한 경우에는 조문의 취지에 비추어 소구채권과 반대채권이 모두 존재하였고 그것이 상계에 의하여 소멸하였다는 판단에 기판력이 생긴다고 보는 것이 통설이다. 상계의 항변은 그 성질상 수동채권의 대하여 증거조사를 하여 그 존재를 확정된 후에 판단하여야 하고 다른 공격방어방법(예컨대 변제항변, 시효소멸의 항변 등)이 모두 이유 없을 때 마지막으로 판단하여야 한다. 또한 상계항변에 의하여 전부 승소한 피고라도 변제의 항변을 인정하여 달라고 상소할 수 있다 즉 상소의 이익이 있다.

IV. 결론

기판력의 물적 범위 = 판결주문 = 소송물이라는 원칙 내지 전통적

77) 대판 2005. 7. 22, 2004다17207.

78) 따라서 상계항변이 실기한 공격방어방법으로 각하된 경우나 성질상 상계가 허용되지 않는 경우에는 기판력이 생기지 않는다.

명제에 따라 규율되고 운영되는 민사소송의 현실에 있어서 구소송물 이론에서와 같이 소송물을 세분화하고 소송물의 개념을 제한하여 좁게 파악할 경우, 기판력의 범위 역시 좁아지게 되는 결과, 사회적으로나 경제적으로 하나인 법률상의 분쟁에 관하여 당사자가 후소에서 전소와 법률적 관점 내지 법률적 견해만 달리하면 전소의 기판력이 후소에 미치지 않게 되므로 패소당사자는 계속 반복하여 동일한 목적의 소송을 진행할 수 있게 된다. 그 결과 법적 안정을 이룩할 수 없게 됨은 물론이고 분쟁의 1회적 해결을 도모할 수 없게 됨으로써 소송경제에 반하게 되는 등의 치명적인 결점이 초래되게 된다. 반면 신소송물이론에 의하여 원고가 소를 통해서 달성하고자 하는 사회적, 경제적 목적이 표시되는 청구의 취지 또는 청구의 취지와 청구의 원인을 이루는 사실관계를 소송물의 구성요소 내지 식별기준으로 로 파악하게 되면 소송물의 크기가 확대되게 되고 그 결과 기판력의 범위 역시 확장되게 됨으로써 결국 법적 안정성과 아울러 소송경제까지 도모할 수 있게 된다. 이러한 점에 비추어 볼 때 소송물 개념은 신소송물이론에 의하여 파악하는 것이 타당할 것이다.⁷⁹⁾ 다만 구소송물이론에서 지적하는 바와 같이 신소송물이론을 취할 경우 필연적으로 확장되는 기판력에 의하여 당사자의 신소 제기권 또는 권리구제의 기회가 부당하게 박탈되지 않도록 당사자는 가능한 모든 법률적 관점 내지 공격 방어방법을 청구의 원인에서 기재하거나 변론에서 주장하는 것이 필요하고 법원 역시 이에 대한 권유를 주저하지 말아야 할 것이며 민사소송법 제136조 소정의 석명권 내지 지적의무를 보다 적극적으로 행사하여야 할 것이다. 또한 앞서 본바와 같이 판결이유 중의 판단인 선결적 법률관계에 관하여 기판력이 생기지 않는다는 원칙을 형식적

79) 앞서 본바와 같이 우리나라에서의 일분지설은 기판력의 범위에 관하여 이분지설과 같은 결론을 내고 있다.

으로 관찰할 경우 초래되는 문제점, 즉 법원에 의하여 소송물에 관한 중국적인 판단을 받았음에도 불구하고 분쟁은 완전히 해결되지 않고 반복될 가능성이 상존하게 되고 그 결과 전소와 모순, 저촉되는 판결이 발생되어 법원에 대한 불신이 야기될 수 있다는 등의 문제점을 해결하기 위해서는 일정한 경우 선결적 법률관계에 관한 판단에도 구속력을 인정할 필요가 있다고 본다. 즉 당사자의 소송행위가 우리 민사소송법 제1조 제2항 소정의 신의성실의 원칙에서 파생되는 선행행위와 모순되는 거동금지에 저촉되는 것으로 판단되는 경우 이를 금지함과 아울러 권리실효의 법리⁸⁰⁾를 적용함으로써 선결적 법률관계에 관한 판단에도 구속력을 인정하여야 할 것이고 또한 현재 판례가 취하고 있는 증명효 이론 역시 적극적으로 활용되어야 할 것으로 생각한다.

80) 이는 전소에서 권리행사를 게을리 한 패소 당사자는 전소 판결이유 중의 판단에 관하여 이미 해결되었다는 상대방의 정당한 신뢰가 생긴 이상, 후소에서 그 신뢰를 뒤집는 동일 문제를 내세워 전소 판결이유 중의 판단에 모순·저촉되는 주장을 하는 것이 허용되지 않는다는 것이다. 전병서, 앞의 책, 669면.

[참고문헌]

1. 국내문헌

- 이시윤, 신민사소송법, 박영사, 2004.
 이시윤·조관행, 판례해설 민사소송법, 두성사, 2002.
 정동윤·유병현, 민사소송법, 법문사, 2006.
 전병서, 민사소송법강의, 법문사, 2003.
 오시영, 민사소송법, 학현사, 2004.
 김용진, 민사소송법, 신영사, 2003.
 강현중, 민사소송법, 박영사, 2002.
 김홍규, 민사소송법, 삼영사, 2005.
 방순원, 민사소송법(상), 한국사법행정학회 1987.
 강현중, "기관력의 객관적 범위", 법조 제35권 9호.
 전병서, "기관력의 객관적 범위", 고시계 97. 11.
 유병현, "기관력과 진정명의회복을 위한 소유권이전등기소송", 고려법학 제39호, 2002. 11
 국순욱, "기관력의 본질과 작용", 민사법 연구 제11집 제1호.
 송명호, "기관력의 문제를 중심으로 한 진정명의회복을 위한 소유권이전등기에 관한 고찰", 법조 52권 11호, 2003. 11,
 김홍엽, "소유권이전등기의 말소등기청구소송과 진정명의회복을 위한 이전등기 청구소송에 있어서 기관력의 문제", 법조통권544권 2002. 1,
 김재형, "진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구의 허용범위", 김용준 헌법 재판소장 회갑기념, <재판의 한길>
 이충상, "진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구와 기관력", 저스티스 통권 66호
 김오수, "진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구와 기관력의 문제", 민사재판의 제문제 제9권
 김황식, "진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구의 당부", 민사판례연구 IV
 홍기문, "소송물이론에 관한 소고", 민사소송 2006.

2. 외국문헌

- 新堂幸司, 民事訴訟法, 筑摩書房, 1991.
 新堂幸司, 新民事訴訟法, 弘文堂, 1998.
 秋山幹男 외 5人, コメントール 民事訴訟法Ⅱ, 日本評論社, 2006.
 兼子一, 民事訴訟法體系, 酒井書店, 1982.
 柏木邦良 "訴訟物概念の機能", 民事訴訟法の争点 (ジュリスト新版), 1988. 7.
 Rosenberg, Die Veränderung des rechtlichen Gesichtspunkts im Zivilprozeß, ZZP 49.
 Arens, Zur Anspruchskonkurrenz bei mehreren Haftungsgründen, AcP 170(1970)